GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 025.828/2021-5 [Apensos: TC 028.099/2020-6, TC 034.053/2023-9]
Natureza: Pedido de Reexame (em Representação)
Unidade: Ministério da Saúde
Responsáveis: Alex Lial Marinho (051.576.527-98); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98).

SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO. CONTRATO 59/2018. PRESTAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE INSUMOS CRÍTICOS DE SAÚDE (ICS). IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO. APLICAÇÃO DE MULTAS. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES DE UM RESPONSÁVEL INAPTAS A REFORMAR O JUÍZO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE AGENTE PÚBLICO EM VIRTUDE DA CONFECÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL SEM EFEITO DECISÓRIO. PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, a qual contou com a anuência de diretor da unidade (peças 331-332):

"INTRODUÇÃO

1. Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias (peça 310) - na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS) e signatário do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, e Alex Lial Marinho (peça 312) - na condição de Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLOG/DLOG/SE/MS), contra o Acórdão 651/2023-TCU-Plenário (peça 283), rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente;

9.2. acatar as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG;

9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos senhores Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho;

9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado:

Responsável	*Valor (R$)*
Roberto Ferreira Dias	*79.004,53*
Alex Lial Marinho	*50.000,00*

9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea 'a', e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

9.6. determinar ao Comando do Exército/Ministério da Defesa o desconto parcelado da dívida na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

remuneração do sr. Alex Lial Marinho Lomanto, observados os limites impostos pela legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992;

9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;

9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU;

9.9. inabilitar o sr. Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992;

9.10. independentemente da interposição de recursos com efeito suspensivo em face dos demais itens desse acórdão, autuar os seguintes processos apartados:

9.10.1. representação com a finalidade de examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço '2.7 - Manipulação de item para atendimento', propondo à Presidência do TCU que fixe a competência do ministro Vital do Rêgo para relatar a matéria por prevenção ao TC 029.554/2022-5, com base nos artigos 9º, 10 e 17 da Resolução 346/2022;

9.10.2. representação tendo por objeto esclarecer as razões para a majoração de preços na aquisição (de R$ 503.880,33 para R$ 3.680.000,00) realizada por requisição administrativa de sete usinas geradoras de oxigênio;

9.10.3. tomada de contas especial em razão do suposto pagamento indevido à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG a título de fretamento de aeronave, no valor de R$ 150.157,03;

9.10.4. tomada de contas especial em face da inexistência de documentação suficiente e hábil para comprovar o alegado fretamento de aeronave ou mesmo a realização pela contratada da operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, com suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15;

9.11. nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Saúde, em relação ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que retenha cautelarmente os valores referentes aos subitens 9.10.3 e 9.10.4 deste acórdão dos pagamentos devidos à empresa contratada até que este Tribunal delibere sobre o mérito da matéria;

9.12. dar ciência deste acórdão aos representantes, ao Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal, ao Departamento de Polícia Federal e à Controladoria-Geral da União.

HISTÓRICO

2. Cuidam os autos de representação protocolada pelos senadores da República Eliziane Gama e Alessandro Vieira, referente a possíveis irregularidades na formalização dos Termos Aditivos 1/2021 e 2/2021 ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTC Log, para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) do Ministério, incluindo as atividades de Modernização Administrativa e Operação das Cadeias de Armazenamento e Distribuição desses insumos, sendo os serviços contratados sob demanda, e sem disponibilização de mão de obra exclusiva (peça 1).

2.1. Consta da peça inicial que, em 24/2/2021, foi publicado no DOU o Extrato do Termo Aditivo 1/2021, cujo objeto foi o acréscimo de R$ 88.750.000,01 ao item 1, equivalente a, aproximadamente, 18,29% do valor do Contrato 59/2018. Em 24/5/2021, foi publicado no DOU o Extrato do Termo Aditivo 2/2021, cujo objeto foi a alteração da redação do subitem 7.14.8 do anexo I do Termo de Referência (TR), vinculado ao edital, e, consequentemente, da Cláusula Oitava - Do regime de execução dos serviços e da fiscalização do contrato.

*2.2. Em despacho à peça 25, em linha de consonância com a unidade técnica (peças 22-24), o Ministro-Relator **a quo** adotou **medida cautelar**, sem oitiva prévia da parte, e determinou que o Ministério da Saúde suspendesse os efeitos jurídicos do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. (VTCLOG) e que se abstivesse de realizar qualquer pagamento referente ao serviço de 'Manipulação de Item para Atendimento (picking)', até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria. A medida cautelar foi referendada por meio do Acórdão 2178/2021-TCU-Plenário, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER (peça 36).*

*2.3. Posteriormente, Alex Lial Marinho e Roberto Ferreira Dias foram ouvidos em **audiência** (peças 176-177), no que interessa ao presente exame recursal (por se tratar da única irregularidade que ensejou*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

sanção aos responsáveis ora recorrentes), respectivamente, na condição de Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde/CGLOG/DLOG/SE/MS e de Diretor do Departamento de Logística em Saúde DLOG/SE/MS e signatário do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018; em virtude da seguinte irregularidade:

*a) **irregularidade**: celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 sem a devida análise tecnicamente fundamentada capaz de fornecer qualquer embasamento para a alteração cogitada, instrumento que viria a alterar substancialmente normas e condições originalmente estabelecidas no edital da licitação, dando causa a modificação ou vantagem em favor da contratada Voetur/VTCLOG durante a execução contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual, ato que constitui indício do cometimento de fraude à licitação. A irregularidade é agravada pelo fato de o aditamento haver sido feito apesar de a contratada não haver atendido a reiteradas requisições feitas anteriormente de prestar informações detalhadas e apresentar relatórios da volumetria manuseada, impossibilitando que fosse realizada '**a verificação dos números e quantitativos apresentados a fim de dirimir e adotar medidas que visem a proteção e economicidade junto ao erário público**', o que inviabilizava 'o atesto de pagamento do item, bem como a fiscalização da execução desse serviço' (peça 93, p. 13-14, grifou-se). Ademais, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde havia apontado diversas fragilidades no objeto do pleito, havendo alertado reiteradamente os gestores quanto a ser 'imprescindível que se demonstre que a alteração a ser efetivada por meio da formalização do Termo Aditivo trará benefícios técnicos e econômicos para a Administração, e se fundamentam em regras claras e tecnicamente comprováveis' (peça 152, p. 22, grifou-se), havendo suscitado, ao final, diversas orientações a serem atendidas previamente à celebração do ajuste e grifado: '**A inobservância das recomendações desta CONJUR/MS implicará a não chancela deste órgão jurídico**' (peça 152, p. 24, grifos no original). Apesar dos alertas efetuados pela Divisão de Formalização de Contratos, pela Coordenação de Compras e Licitações e, especialmente, pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, unidades vinculadas à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, quanto à necessidade de 'apresentação de esclarecimentos robustos quanto aos pontos levantados' pela Consultoria Jurídica e da recusa dos fiscais de contrato de produzir nova manifestação apta a esclarecer os questionamentos, o 2º Termo Aditivo foi formalizado sob o argumento de que pagar cerca de R$ 19 milhões é mais vantajoso do que pagar R$ 57,7 milhões, valores elaborados unilateralmente pela Voetur/VTCLOG, tendo como único fundamento a mesma Nota Técnica 2/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 4/3/2021, que motivara os questionamentos suscitados pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde;*

*a.1) conduta de Roberto Ferreira Dias: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde DLOG/SE/MS elaborou a Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 13/4/2021, SEI 0019952627 / 25000.033893/2017-57 (peça 152, p. 36-38), que assina isoladamente, com a finalidade responder aos questionamentos efetuados pela Consultoria Jurídica, havendo afirmado, em síntese, que a alteração cogitada na forma de mensuração e pagamento do serviço de **picking** não iria modificar o objeto do contrato, não sendo capaz de prejudicar o procedimento licitatório, declarando, ainda, que haveria 'vantajosidade para o item alterado', o que restaria comprovado pela Nota Técnica 2/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 4/3/2021, o mesmo documento que motivara os questionamentos suscitados pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Porém, admitiu que haveria 'acréscimo da quantia referente ao **picking**', mas limitando-se a indicar que '**a equipe de fiscalização do contrato irá monitorar a utilização do orçamento e, caso necessário, será solicitado, no momento oportuno, a complementação na informação da disponibilidade orçamentária**' (peça 152, p. 37-38, grifos no original), o que evidencia a ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Apesar dos alertas efetuados pela Divisão de Formalização de Contratos, pela Coordenação de Compras e Licitações e, especialmente, pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, unidades vinculadas à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, quanto à necessidade de 'apresentação de esclarecimentos robustos quanto aos pontos levantados' pela Consultoria Jurídica e da recusa dos fiscais de contrato de produzir nova manifestação apta a esclarecer os questionamentos, dada a ausência de embasamento para a alteração cogitada, manifestou-se 'de acordo' com a Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, elaborada pelo senhor Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) na qual, a título de informação e resposta, transcreve trechos de apontamentos e recomendações efetuadas pela Consultoria Jurídica e indica que já teriam sido 'devidamente justificadas' pela Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, havendo afirmado, ainda, que '**não haverá impacto nas cláusulas econômico-financeiras para o contrato**', em evidente contradição com o que fora assinalado na citada Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, elaborada pelo responsável, o*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

*que também corrobora a constatação da ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Ato contínuo, o responsável exarou Despacho, datado de 12/5/2021, mas assinado às 10:57 horas do dia 13/5/2021, encaminhando o processo para a Coordenação-Geral de Análise das Contratações de Insumos Estratégicos para a Saúde para a adoção das 'providências necessárias', '**na urgência que o caso requer**' (peça 52, p. 57, grifos no original), havendo convocado a Voetur/VTCLOG, em 18/5/2021, a assinar o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato irregular que foi materializado no dia 20/5/2021, conduta sobre a qual incide o disposto no art. 82 da Lei 8.666/1993;*

*a.2) conduta de Alex Lial Marinho: na condição de Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde/CGLOG/DLOG/SE/MS, emitiu Despacho, em 14/4/2021, encaminhando o processo com a Nota Técnica 4/2021- CGLOG/DLOG/SE/MS à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, assinalando que ela continha 'os apontamentos necessários à continuidade do fluxo processual inerente à aditivação do contrato... retorna-se o processo à SAA/MS para que seja redigido o Termo Aditivo ao Contrato 59/2018' (peça 152, p. 39), com o que expressou plena concordância com a manifestação produzida pelo senhor Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98). Em posterior Despacho, datado de 11/5/2021, endereçado ao 'Gabinete do Departamento de Logística DLOG/SE/MS', em que, considerando a assinatura do Termo de Sub-Rogação do Contrato 59/2018, em 7/5/2021, e 'a necessidade de dar célere andamento aos trâmites administrativos referentes ao reajuste do aludido contrato e ao **picking**' assinala que '**O DLOG, por meio da Nota Técnica 4 (id 0019952627), respondeu aos questionamentos da CONJUR, mas a SAA, via CGMAP (id 0020137615), considerou que ainda há pontos suscitados pela CONJUR a serem esclarecidos, o que ocorreu na Nota Informativa 14 (id 0020495344)'.** Na referida Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (peça 152, p. 50-51), elaborada por ele próprio, o responsável transcreve trechos de apontamentos e recomendações efetuadas pela Consultoria Jurídica e indica que já teriam sido 'devidamente justificadas' pela Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, havendo afirmado, ainda, que '**não haverá impacto nas cláusulas econômico-financeiras para o contrato**', em evidente contradição com o que fora assinalado na citada Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, o que também corrobora a constatação da ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Os atos praticados pelo responsável contribuíram para a formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato irregular que foi materializado no dia 20/5/2021, conduta sobre a qual incide o disposto no art. 82 da Lei 8.666/1993.*

2.4. Em seguida, esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1502/2022-TCU-Plenário (peça 241), rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER, deliberou por revogar a medida cautelar e determinar a oitiva da VTCLOG para que se manifeste sobre as irregularidades listadas pela unidade técnica à peça 236.

2.5. Após o regular desenvolvimento do processo, o Plenário deste Tribunal, por meio do Acórdão 651/2023 (peça 283), rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER, deliberou, no que interessa para o deslinde dos recursos: (i) aplicar a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a Alex Lial Marinho e a Roberto Ferreira Dias; (ii) inabilitar Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992.

2.6. Irresignados, Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho interpuseram pedidos de reexame contra o Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, espécie de recurso objeto do presente exame.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE

3. Reitera-se a proposta de conhecimento dos recursos, nos termos dos exames de admissibilidade de peça 313-315 e do despacho de peça 318 do Ministro Jorge Oliveira.

EXAME DE MÉRITO

4. Delimitação

4.1. Primeiramente, observa-se que o primeiro conjunto de achados (itens 11 a 22 do voto), que dizia respeito à celebração do primeiro termo aditivo, em 19/2/2021, por meio do qual ocorreu o aditamento para acréscimo em 25% do item 1 – Transporte do Contrato 59/2018 (o valor passaria de R$ 355.000.000,05 para R$ 443.750.000,06) (peças 11, p. 1-6, e 175), não ensejou a sanção pecuniária (vide item 22 do voto).

4.2. Ademais, salienta-se que os argumentos apresentados nos recursos em face do segundo conjunto de achados (itens 23 a 36 do voto), que diz respeito à execução contratual, serão apurados nos processos de tomada de contas especial instaurados com vistas a apuração dos fatos e identificação dos responsáveis (TCs 006.791/2023-9 e 006.792/2023-5).

4.3. Assim, as sanções cominadas aos gestores fundamentaram-se no terceiro conjunto de achados diz respeito ao segundo termo aditivo (vide itens 37 a 71 do voto), que tratou do serviço de manipulação de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

*itens (**picking**), o qual corresponde a cerca de 4% do valor total contratado.*

4.4. Desta feita, o presente exame contempla as seguintes questões:

a) preliminar:

a.1) ocorrência da prescrição;

b) mérito:

b.1) ausência de culpabilidade na celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018;

b.2) desproporcionalidade e desarrazoabilidade das sanções;

b.3) ocorrência de boa-fé; e

b.4) ausência de má-fé.

4.5. Registra-se que o presente exame atentará além dos elementos constantes da matriz de responsabilização utilizada pelo TCU para a questão da responsabilidade subjetiva, também naqueles constantes no Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), mormente no que concerne aos seus arts. 22 e 28.

Preliminar

5. Ocorrência da prescrição

5.1. Embora os recorrentes não tenham alegado a prescrição para o exercício da pretensão punitiva do TCU, por se tratar de matéria de ordem pública, o exame da questão se impõe, consoante disposto no art. 10 da Resolução TCU 344/2022.

Análise:

5.2. É prescritível o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos dos arts. 37, §5º, da Constituição Federal e 1º da Lei 9.873/1999, regulamentada, no âmbito do TCU, pela Resolução TCU 344/2022.

5.3. O exame da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU será realizado com base na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a Lei 9.873/1999 quanto a essa matéria (art. 1º da Resolução TCU 344/2022).

*5.4. **In casu**, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição. Com efeito, o prazo de prescrição começou a correr em 22/7/2021 (peça 1), correspondente à data do recebimento da representação pelo Tribunal, quanto às apurações decorrentes de processos dessa natureza (art. 4º, inciso III, da Resolução-TCU 344/2022). A prescrição foi interrompida na seguinte data em 5/4/2023, data do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário (peça 283), por causa interruptiva elencada no art. 5º da citada resolução.*

5.5. A partir das causas interruptivas acima e tendo em vista o disposto nos arts. 2º e 8º da Resolução-TCU 344/2022, observa-se que não ocorreu a prescrição principal, tampouco a intercorrente, uma vez que não houve transcurso temporal superior a cinco anos, entre o marco inicial e a primeira causa interruptiva, muito menos, na sequência, paralisação do processo por mais de três anos.

Mérito

6. Ausência de culpabilidade na celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018

6.1. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho trazem a tese de que não teriam agido com culpa na celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, tendo apresentado, para tanto, os seguintes argumentos (peças 310, p. 6-17; e 312, p. 12-25 e 29-30):

a) o planejamento e assinatura do Contrato 59/2018 não teriam ocorrido na gestão de Roberto Ferreira Dias, salientando-se que, desde o início, teriam sido verificadas inconformidades referentes ao planejamento da contratação, o que teria maculado os aditivos do contrato (peça 310, p. 6);

b) o ato irregular imputado a Roberto Ferreira Dias seria um de diversos atores do Ministério da Saúde, o qual teria tido início justamente com a negativa dele em efetuar pagamentos nos termos do contrato e dispendesse R$ 57 milhões do erário (peça 310, p. 7);

c) erro grosseiro seria rescindir o Contrato 59/2018 durante a pandemia, o que poderia gerar indagações a Roberto Ferreira Dias do motivo de não ter sido pago valor menor que o do contrato ou o preço de uma vida ou o atraso na entrega de insumos e medicamentos (peça 310, p. 8);

d) para Roberto Ferreira Dias, o ato de decidir do gestor em um contrato toleraria o erro indenizável do gestor público (peça 310, p. 8);

e) para Roberto Ferreira Dias, o SKU não seria um termo objetivamente claro, sendo que esta métrica faria sentido em armazéns que possuem grandes variedades de itens (grande quantidade de SKUs), sendo inaplicável ao Ministério da Saúde (baixa variedade de itens, alto valor agregado e quantitativo para abastecer o SUS) - peça 310, p. 8-9;

f) para Roberto Ferreira Dias, a premissa do gestor à época da elaboração do termo de referência teria sido

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

falsa, pois desconsiderou que a distribuição de medicamentos apenas aumenta, ainda mais considerando itens jamais previstos no contrato (fato superveniente dos efeitos de uma pandemia) - peça 310, p. 9;
g) para Roberto Ferreira Dias, não haveria motivo para criminalizar a alteração contratual qualitativa que apenas teve o intuito de manter o Contrato 59/2018 ao longo de uma pandemia (peça 310, p. 9-10);
h) Roberto Ferreira Dias teria agido contrariamente ao interesse da empresa, com as glosas de valores indevidamente cobrados, salientando-se que não seria o ordenador de despesa ou responsável pelo orçamento (peça 310, p. 10);
i) não haveria erro grosseiro na conduta de Roberto Ferreira Dias, pois sua interpretação não estaria alheia ao disposto no contrato e no termo de referência (peça 310, p. 10);
j) os efeitos da pandemia não foram sopesados na aferição da culpabilidade de Roberto Ferreira Dias, ao contrário do que teria havido em relação ao 1º Termo Aditivo do Contrato 59/2018 (peça 310, p. 10);
k) para Roberto Ferreira Dias, a questão da pandemia teria sido sopesada pelo MPTCU (peça 310, p. 11);
l) diante da pandemia e de uma eventual rescisão contratual, a margem de atuação de Roberto Ferreira Dias não poderia ser considerada ampla e de fácil resolução, pois o serviço contratado seria imprescindível para a distribuição de vacinas e outros insumos de saúde (peça 310, p. 11);
m) para Roberto Ferreira Dias, não se poderia considerar erro grosseiro a celebração do 2º Termo Aditivo para que fosse adotada métrica do volume de transporte, haja vista que seria capaz de mensurar o real quantitativo de itens ao mesmo tempo que resguardaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (peça 310, p. 12);
*n) para Roberto Ferreira Dias, a culpa grave não teria ocorrido, uma vez que o Ministro-**Relator a quo** verificou que havia uma divergência interpretativa sobre a cláusula do edital alusiva ao 2º Termo Aditivo (peça 310, p. 13);*
o) diante da pandemia e da necessidade de resposta ágil para atender aos anseios da população, Roberto Ferreira Dias não poderia, considerando todos os fatores colocados à sua disposição para decidir e o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da contratada, deixar de firmar o 2º Termo Aditivo (peça 310, p. 13);
p) para Roberto Ferreira Dias, nos autos do TC 012.717/2021-5, o TCU teria considerado a pandemia para afastar a responsabilidade do gestor (peça 310, p. 14);
*q) para Roberto Ferreira Dias, não teria havido dano ao erário **in casu** (peça 310, p. 14 e 16-17);*
r) a empresa contratada (descumpriu o item 7.5 do Termo de Referência) não teria sido apenada, mesmo tendo concorrido com o erro atribuído a Roberto Ferreira Dias (peça 310, p. 14-15);
s) dever-se-ia considerar na culpabilidade de Roberto Ferreira Dias as consequências práticas da decisão, considerando os percalços por ele enfrentados - execução da avença em termos inovadores, fixação de parâmetro licitatório de que não teria participado, existência de dúvida razoável quanto à melhor intelecção da cláusula contratual, o cenário de pandemia; tendo sido considerado fato abstrato como circunstância agravante (peça 310, p. 16-17);
*t) os atos praticados por Alex Lial Marinho não poderiam ser enquadrados como erro grosseiro, em virtude de: (i) dúvida acerca do termo 'item' do item 7.14.8 do termo de referência persistente por dois anos (inclusive em período antes de sua nomeação) até a manifestação dele por meio da Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS; (ii) no próprio voto condutor, o Ministro-Relator **a quo** teria reconhecido a divergência interpretativa sobre o item do edital; e (iii) no parecer de Marçal Justen Filho, restaria evidente o caráter inovador e complexo do edital e do contrato, trazendo omissão e incerteza em relação ao conceito de 'item' (peça 312, p. 6-12, 17 e 19);*
u) para Alex Lial Marinho, ele teria duas posições como gestor ante a complexidade da questão objeto da questão do 2º Termo Aditivo: (i) omissão ou protelação; e (ii) resolução (sendo ele punido por erro de interpretação) - peça 312, p. 12;
v) para Alex Lial Marinho, ele estaria sendo sancionado por interpretação diferente daquela adotada posteriormente pelo TCU, o que seria inadmissível (peça 312, p. 13-15);
w) para Alex Lial Marinho, o edital e o contrato não trariam de forma clara o modo de remuneração do item, obrigando os gestores a adotarem a hermenêutica diante da omissão e da incerteza (peça 312, p. 14-15);
*x) para Alex Lial Marinho, ao adotar uma solução 'meio termo' para o contrato, tinha-se em mente as vidas em risco e uma eventual rescisão contratual por parte da contratada por não ter obtido resposta final acerca da forma de remuneração do item '**picking**' (situação que teria se arrastado desde novembro de 2019) - peça 312, p. 15;*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

y) pareceres de mestres da UnB (peça 63, p. 1-9) e de Marçal Justen Filho (peça 254) seriam no sentido de não ser razoável a precificação por SKU, entendimento esse diverso daquele adotado pelo TCU (peça 312, p. 16-17);
z) o objeto do 2º Termo Aditivo não teria sido sanar nulidade, mas sim dirimir controvérsia sobre o real significado de 'item' constante do item 7.14.8 do Termo de Referência, situação que teria se alongado desde fevereiro de 2019 (peça 312, p. 17);
aa) a obscuridade, omissão e incerteza teriam levado o TCU a se manifestar sobre a interpretação da cláusula, o que indicaria dificuldade (não obviedade) para um gestor médio (peça 312, p. 17);
ab) a mudança de metodologia de medição teria diminuído de R$ 57 milhões para aproximados R$ 19 milhões, com uma economia inicial de quase R$ 40 milhões - o que seria razoável (peça 312, p. 17);
ac) o que seria inverossímil e irreal seria a diminuição de R$ 57 milhões (metodologia usada ao longo da execução do contrato) para R$ 1 milhão (tese da SKU adotada pelo TCU) - peça 312, p. 18;
ad) não teria havido a adoção de 'meio termo', mas de metodologia mais próxima da realidade contratual (peça 312, p. 18);
ae) o contrato estaria viciado desde o início (planejamento), do qual Alex Lial Marinho não teria participado, por não definir claramente a metodologia para medição e remuneração da manipulação dos itens (peça 312, p. 18);
af) a missão dos que assumiram depois seria 'salvar' o contrato, sendo impensável a rescisão do contrato em meio a pandemia da Covid-19 e a licitação complexa de solução logística em curtíssimo espaço de tempo (peça 312, p. 18-19);
*ag) o objetivo da celebração do 2º Termo Aditivo seria sanar dúvidas sobre o conceito de 'item' na atividade **picking**, que acontecia desde fevereiro de 2019, com a suspensão de todos os pagamentos em relação à atividade, e não para beneficiar a empresa contratada (peça 312, p. 19);*
ah) a conclusão da unidade técnica pela tese do SKU teria ocorrido depois das condições dos gestores, os quais estavam pressionados pelo tempo de decisão e no contexto pandêmico (peça 312, p. 20);
ai) Alex Lial Marinho teria apenas dado encaminhamento (sem juízo de valor), por meio de despachos, à Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, que tinha por finalidade responder aos questionamentos efetuados pela Consultoria Jurídica, elaborada e assinada unicamente pelo Diretor do Departamento Logístico, superior imediato dele (peça 312, p. 20-23);
aj) Alex Lial Marinho não teria expressado sua concordância com a Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, haja vista o poder hierárquico (não caberia anuir, fiscalizar ou manifestar concordância) – peça 312, p. 22-23 e 25; e
ak) a Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (sem conter opinião técnica ou subsídio para tomada de decisão) teria sido elaborada somente para transcrever informações contidas no parecer jurídico da Consultoria Jurídica e na Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (peça 312, p. 24-25); e
al) não se poderia confundir divergência de interpretação com erro grosseiro, porquanto se tratava de questão complexa e a dificuldade estava além do entendimento do gestor público médio; tendo trazido precedentes do TCU (Acórdãos 4447/2020-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES; 1628/2018-TCU-Plenário, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER; e 2860/2018-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN) - peça 312, p. 29-30.
Análise:
6.2. Os responsáveis ora recorrentes foram apenados pelo TCU em virtude da irregularidade listada no item 2.3 supra. Assim sendo, a análise destes recursos será realizada com foco nos argumentos atinentes à celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 sem a devida análise tecnicamente fundamentada capaz de fornecer qualquer embasamento para a alteração cogitada, instrumento que viria a alterar substancialmente normas e condições originalmente estabelecidas no edital da licitação, dando causa a modificação ou vantagem em favor da contratada Voetur/VTCLOG durante a execução contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual, ato que constitui indício do cometimento de fraude à licitação.
6.3. Inicialmente, insta consignar que o parecer do MPTCU é meramente opinativo, não detendo ele caráter vinculante às decisões colegiadas desta Corte de Contas, formada por seus ministros e ministros-substitutos. A competência para julgar as contas dos administradores públicos encontra-se no art. 71, inciso II, da Magna Carta.
6.4. Com efeito, o julgador não está compelido a considerar todas as alegações da parte, desde que tenha elementos que entenda serem suficientes para formar sua convicção; tampouco está obrigado a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

examinar todas as considerações da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, cujos entendimentos e argumentos servem para fornecer subsídios e não vinculam a formação da convicção do Tribunal (Acórdão 1561/2017-TCU-Plenário, rel. Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO).

6.5. O relator, que preside a instrução do processo, pode acolher qualquer uma das manifestações técnicas contidas no processo, ou até ser contrário a todas, para formação do seu livre convencimento e busca da verdade material (Acórdão 2307/2018-TCU-Plenário, rel. Ministra ANA ARRAES).

*6.6. Em relação às **alegações** de **Alex Lial Marinho**, vê-se que essas **não devem ser acatadas**. Senão, veja-se. Alegações de falha no planejamento relativo ao Contrato 59/2018, de suposta economia ao erário (R$ 18 milhões ao invés de R$ 57 milhões), e o caráter inovador e complexo do edital e do contrato - **não justificam a celebração do 2º Termo Aditivo, desprovida de estudos técnicos e de viabilidade jurídica, com a adoção de 'meio termo' sugerido pela empresa contratada para 'salvar o contrato'**. Os atos praticados pelo responsável devem ser enquadrados como erro grosseiro e não como erro de interpretação, porquanto **não se observou a existência de estudos técnicos e de viabilidade jurídica, além de o ato ser contra o edital e antieconômico**. A dúvida acerca do termo 'item' do item 7.14.8 do termo de referência não serve de anteparo para adoção de medida imprudente e/ou negligente de Alex Lial Marinho ao se posicionar a favor da solução adotada no 2º Termo Aditivo. Ao contrário do alegado pelo recorrente, não há que se falar em dúvida do Ministro-Relator **a quo** acerca do método do supracitado do edital, conforme se observa nos itens 6.15 e 6.16 infra. Ainda que houvesse dúvida, Alex Lial Marinho deveria ter se posicionado desfavoravelmente à solução adotada no 2º Termo Aditivo, porquanto essa se encontrava desprovida de estudos técnicos (incluso impacto financeiro) e de viabilidade jurídica. O que ocorreu foi a aceitação de proposta 'meio termo' da contratada.*

6.7. Apesar do período pandêmico, a adoção de uma solução 'meio termo' jamais poderia ser cogitada, pois não se encontrava respaldada por estudos técnicos e não encontrava viabilidade jurídica (nos termos do edital e do contrato). O fato de a situação ter se arrastado desde 2019 demonstra a ineficiência do órgão na sua tomada de decisões e não justifica a adoção de solução imprudente e/ou negligente dos gestores ora recorrentes.

6.8. Pareceres de mestres da UnB e de Marçal Justen Filho não socorrem aos recorrentes, pois, embora sejam opiniões válidas, não são peremptórias para justificar a celebração do 2º Termo Aditivo, devendo-se considerar que tais ideias se mostraram equivocadas pelo próprio Ministério da Saúde posteriormente, conforme itens 6.15 e 6.16 infra. Demais disso, ninguém deveria saber melhor da solução a ser dada ao caso concreto do que o próprio corpo técnico do aludido órgão ministerial, com base em estudos técnicos e de viabilidade jurídica, conforme recomendado pela Consultoria Jurídica e técnicos do Ministério da Saúde. Ressalta-se, por oportuno, que não houve estudos acerca do impacto financeiro da celebração do 2º Termo Aditivo.

6.9. Nesse contexto, cabe mencionar que não se está a se considerar a solução para o significado (interpretação) acerca do termo 'item' do item 7.14.8 do termo de referência como normal para um gestor médio. O que não é normal para o gestor médio, daí o advento do erro grosseiro, é a adoção de medida imprudente e/ou negligente de Alex Lial Marinho ao se posicionar a favor da solução adotada no 2º Termo Aditivo, sem que houvesse estudos técnicos e viabilidade jurídica que justificassem o ato. Se os gestores ora recorrentes tivessem se respaldado em estudos técnicos e de viabilidade jurídica não chegariam à conclusão acerca da celebração do 2º Termo Aditivo, podendo eles terem chegado à solução pela metodologia SKU, como foi decidido pelo Ministério da Saúde posteriormente, conforme itens 6.15 e 6.16 infra. Cabe registrar que, em nenhum momento destes autos, este Tribunal aventou a rescisão do Contrato 59/2018 durante a pandemia, mas sim que o Ministério da Saúde adotasse, em sua tomada de decisão para celebração de aditivo, critérios técnicos e com viabilidade jurídica para alterar qualitativamente o instrumento contratual.

*6.10. Alex Lial Marinho não apenas deu andamento ao processo, como corroborou com a opinião de Roberto Ferreira Dias, considerando respondidos os questionamentos da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Isso encontra-se didaticamente explicitado no voto condutor do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, **in verbis** (peça 284, p. 10):*

> *73. O sr. Alex Lial Marinho, então Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde, elaborou, 4/3/2021, nota técnica solicitando a realização do aditivo contratual nos seguintes termos (peça 152, p. 7):*
>
> *'A contraproposta da contratada, por sua vez, representa um 'meio-termo' entre esses dois métodos, correspondendo a R$ 18.983.096,10 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e três mil noventa e seis reais e dez centavos), calculado por volume expedido, tornando-se assim mais vantajosa ao erário, se*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

comparado ao redigido no contrato.' (grifou-se)

74. Não procede, pois, o argumento de que não participou do processo decisório de celebração do segundo termo aditivo.

6.11. A própria conduta de Alex Lial Marinho demonstra cabalmente sua participação no processo decisório de celebração do 2º Termo Aditivo:

*na condição de Coordenador-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde/CGLOG/DLOG/SE/MS, emitiu Despacho, em 14/4/2021, encaminhando o processo com a Nota Técnica 4/2021- CGLOG/DLOG/SE/MS à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, assinalando que ela continha 'os apontamentos necessários à continuidade do fluxo processual inerente à aditivação do contrato... retorna-se o processo à SAA/MS para que seja redigido o Termo Aditivo ao Contrato 59/2018' (peça 152, p. 39), com o que expressou plena concordância com a manifestação produzida pelo senhor Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98). Em posterior Despacho, datado de 11/5/2021, endereçado ao 'Gabinete do Departamento de Logística DLOG/SE/MS', em que, considerando a assinatura do Termo de Sub-Rogação do Contrato 59/2018, em 7/5/2021, e 'a necessidade de dar célere andamento aos trâmites administrativos referentes ao reajuste do aludido contrato e ao **picking**' assinala que 'O DLOG, por meio da Nota Técnica 4 (id 0019952627), respondeu aos questionamentos da CONJUR, mas a SAA, via CGMAP (id 0020137615), considerou que ainda há pontos suscitados pela CONJUR a serem esclarecidos, o que ocorreu na Nota Informativa 14 (id 0020495344)'. Na referida Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (peça 152, p. 50-51), elaborada por ele próprio, o responsável transcreve trechos de apontamentos e recomendações efetuadas pela Consultoria Jurídica e indica que já teriam sido 'devidamente justificadas' pela Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, havendo afirmado, ainda, que 'não haverá impacto nas cláusulas econômico-financeiras para o contrato', em evidente contradição com o que fora assinalado na citada Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, o que também corrobora a constatação da ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Os atos praticados pelo responsável contribuíram para a formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato irregular que foi materializado no dia 20/5/2021, conduta sobre a qual incide o disposto no art. 82 da Lei 8.666/1993. (Grifou-se).*

6.12. Nesse diapasão, cabe ressaltar que a obediência hierárquica não exclui a culpabilidade quando se trata de ordem manifestamente ilegal (Acórdão 856/2016-TCU-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES). Nesse sentido, tem-se o Acórdão 2511/2012-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER. Ou seja, como a ordem de Roberto Ferreira Dias era manifestamente ilegal, cabia ao agente público Alex Lial Marinho não obedecer a tal ordem, qual seja (peça 284, p. 10-11):

75. O Sr. Roberto Ferreira Dias, então Diretor do Departamento de Logística em Saúde, autoridade máxima sobre a questão aqui tratada, elaborou, em 13/4/2021, a Nota Técnica 4/2021 com a seguinte conclusão:

'A presente Nota Técnica responde aos questionamentos interpostos pela CONJUR/MS e, dessa forma, manifesta-se de forma favorável a realização do aditivo contratual para o item 7.14.8 do Termo de Referência, que trata da 'manipulação de item para atendimento' (grifou-se) (peça 152, p. 36-38).

*6.13. Quanto aos **argumentos** trazidos por **Roberto Ferreira Dias** (alíneas 'a' a 's' do item 6.1), entende-se que esses **não merecem prosperar**. Com efeito, alegações de falha no planejamento relativo ao Contrato 59/2018, de suposta economia ao erário (R$ 18 milhões ao invés de R$ 57 milhões), e a execução da avença em termos inovadores - **não justificam a celebração do 2º Termo Aditivo, desprovida de estudos técnicos e de viabilidade jurídica, com a adoção de 'meio termo' sugerido pela empresa contratada para 'salvar o contrato'**. O fato é que o gestor assumiu o risco de estar elevando demasiadamente o custo do Contrato 59/2018. Independentemente do período pandêmico e de uma eventual rescisão contratual, era dever do gestor tomar sua decisão respaldada em estudos técnicos e com viabilidade jurídica, sob pena de tomar decisão temerária aos cofres públicos. A culpabilidade de Roberto Ferreira Dias não se enquadra como erro de interpretação, mas como erro grosseiro, conforme encontra-se sobejamente demonstrado em sua conduta:*

na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde DLOG/SE/MS elaborou a Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 13/4/2021, SEI 0019952627 / 25000.033893/2017-57 (peça 152, p. 36-38), que assina isoladamente, com a finalidade responder aos questionamentos efetuados pela Consultoria Jurídica, havendo afirmado, em síntese, que a alteração cogitada na forma de mensuração e pagamento do serviço de picking não iria modificar o objeto do contrato, não sendo capaz de prejudicar

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

*o procedimento licitatório, declarando, ainda, que haveria 'vantajosidade para o item alterado', o que restaria comprovado pela Nota Técnica 2/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 4/3/2021, o mesmo documento que motivara os questionamentos suscitados pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Porém, admitiu que haveria 'acréscimo da quantia referente ao **picking**', mas limitando-se a indicar que '**a equipe de fiscalização do contrato irá monitorar a utilização do orçamento e, caso necessário, será solicitado, no momento oportuno, a complementação na informação da disponibilidade orçamentária**' (peça 152, p. 37-38, grifos no original), o que evidencia a ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Apesar dos alertas efetuados pela Divisão de Formalização de Contratos, pela Coordenação de Compras e Licitações e, especialmente, pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, unidades vinculadas à Subsecretaria de Assuntos Administrativos, quanto à necessidade de 'apresentação de esclarecimentos robustos quanto aos pontos levantados' pela Consultoria Jurídica e da recusa dos fiscais de contrato de produzir nova manifestação apta a esclarecer os questionamentos, dada a ausência de embasamento para a alteração cogitada, manifestou-se 'de acordo' com a Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, elaborada pelo senhor Alex Lial Marinho (CPF: 051.576.527-98) na qual, a título de informação e resposta, transcreve trechos de apontamentos e recomendações efetuadas pela Consultoria Jurídica e indica que já teriam sido 'devidamente justificadas' pela Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, havendo afirmado, ainda, que '**não haverá impacto nas cláusulas econômico-financeiras para o contrato**', em evidente contradição com o que fora assinalado na citada Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, elaborada pelo responsável, o que também corrobora a constatação da ausência de qualquer análise prévia do impacto financeiro decorrente do aditamento pretendido. Ato contínuo, o responsável exarou Despacho, datado de 12/5/2021, mas assinado às 10:57 horas do dia 13/5/2021, encaminhando o processo para a Coordenação-Geral de Análise das Contratações de Insumos Estratégicos para a Saúde para a adoção das 'providências necessárias', '**na urgência que o caso requer**' (peça 52, p. 57, grifos no original), havendo convocado a Voetur/VTCLOG, em 18/5/2021, a assinar o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, ato irregular que foi materializado no dia 20/5/2021, conduta sobre a qual incide o disposto no art. 82 da Lei 8.666/1993. (Grifou-se).*

6.14. É completamente desprovido de legalidade e economicidade o argumento de que a adoção de métrica do volume de transporte no 2º Termo Aditivo seria capaz de mensurar o real quantitativo de itens ao mesmo tempo que resguardaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o item 2.7 da planilha vencedora do certame, originalmente, previa um custo de R$ 3.858.000,00 (peça 285, p. 3-4), além de que havia a opção de uso da metodologia SKU, aventada pela Coordenadoria de Suporte Jurídico em Procedimentos Licitatórios CJUPLI/GLICI/CONJUR-MS (peça 152, p. 26):

*9. (...) deve se avaliar tecnicamente se há vantajosidade na manutenção do referido contrato ainda que se promova a aditivação pretendida, tendo em vista que caso o método SKU (mais econômico) seja de fato mais adequado ao referido contrato, a continuidade da avença, agora realizando-se o pagamento do '**picking**' por meio do 'Volume Expedido' pode se mostrar desvantajosa para a Administração Pública, podendo até mesmo caracterizar sobrepreço.*

10. Recomenda-se, portanto, que a área técnica avalie outras alternativas, inclusive o de rescisão contratual com a realização de novo procedimento licitatório para a contratação dos serviços, tendo em vista que conforme demonstrado no quadro comparativo, a eleição do método 'Volume Expedido' em detrimento do método SKU pode representar um sobrepreço de mais de 17 milhões de reais, apenas de novembro de 2018 até janeiro de 2021. A providência se torna ainda mais necessária, tendo em vista que o contrato Administrativo 59/2018 foi firmado com vigência de 60 meses, ou seja, permanecerá vigente até 2023.

*11. Outrossim, recomenda-se que haja verificação pelo órgão, tendo em vista que o assunto é eminentemente técnico, se apenas a modificação no item 7.14.8 do Termo de Referência já tem o condão de promover a mudança pretendida pela Administração, isto é, se não há qualquer outra cláusula que trate acerca da mensuração dos serviços de '**picking**' e que possam estar em desacordo com o método que se pretende estabelecer. (Grifou-se).*

6.15. Nesse ponto, cabe trazer à baila trecho do voto condutor do Acórdão 1502/2022-TCU-Plenário, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER (peça 242, p. 10):

*60. Por outro lado, há consenso entre a unidade técnica deste Tribunal e os gestores do Ministério da Saúde de que os pagamentos devem ocorrer mediante a utilização do **SKU** como critério de medida para o serviço*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

*de **picking**, pois esta seria a metodologia prevista no contrato original (Grifou-se).*

6.16. Cumpre trazer à cola, por fim, trecho do voto condutor do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário (peça 284, p. 8-10):

> *51. O Ministério da Saúde cogitou a utilização de uma segunda métrica denominada **Stock Keeping Unit (SKU)**, medição por produto catalogado a cada pedido expedido. (...)*
>
> *60. Em 13/7/2021, a nova gestão do Departamento de Logística do MS (DLOG) apresentou entendimento de que deveria ser utilizada a métrica denominada **SKU** para o serviço (Ofício 218/2021/CGLOG/DLOG/SE/MS, de 13/7/2021, peça 12, p. 45-47).*
>
> *61. Com efeito, a área técnica do Ministério da Saúde argumentou que o conceito de 'item' mencionado no item 7.14.8 do termo de referência diria respeito à metodologia **Stock Keeping Unit – SKU**, uma vez que, sempre que há menção ao termo 'item' no documento, verifica-se haver referência a essa expressão, conforme excertos a seguir (peça 10, p. 100-102):*
>
> *'7.14.12.4 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE ATUALMENTE EXECUTADAS*
>
> *Estão contempladas neste Termo de Referência diferentes operações de transporte, cada uma com características e serviços específicos:*
>
> *7.14.12.4.1 OPERAÇÃO COM BASE EM BRASÍLIA*
>
> *[...]*
>
> *Quantidade de itens (Stock Keeping Unit - SKUs): em torno de 600.*
>
> *7.14.12.4.2 OPERAÇÃO COM BASE NO RIO DE JANEIRO*
>
> *[...]*
>
> *Quantidade de itens (SKUs): em torno de 200.*
>
> *7.14.12.4.3 OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE INSUMOS JUDICIAIS*
>
> *[...]*
>
> *Quantidade de itens (SKUs): em torno de 2500 (dois mil e quinhentos).'*
>
> *65. O primeiro erro dos gestores foi assumir como verdadeira e sem maiores questionamentos essa premissa, baseada em uma simples interpretação literal do termo de referência. Ora, se a conclusão dessa interpretação levava a um resultado absurdo, deveriam ser buscados outros métodos interpretativos para a Administração balizar suas ações, o que não ocorreu (somente a nova gestão do Ministério elaborou uma análise sistemática do edital e concluiu pela validade da metodologia SKU).*
>
> *(...)*
>
> *70. Registro que não se está a falar que devem ser afastadas soluções consensuais no âmbito de contratos administrativos. Entretanto, a condução de soluções consensuais deve ser feita por processos específicos em que se demonstre que o nível de indeterminação do conflito pressupõe como solução mais vantajosa um consenso. No caso concreto, a tese do SKU pareceu se impor como decorrência da interpretação do edital. (Grifou-se).*

6.17. Cabe registrar, mais uma vez, que em nenhum momento destes autos este Tribunal aventou a rescisão do Contrato 59/2018 durante a pandemia, mas sim que o Ministério da Saúde adotasse, em sua tomada de decisão para celebração de aditivo, critérios técnicos e com viabilidade jurídica para alterar qualitativamente o instrumento contratual. Não há que se falar em erro indenizável do gestor público, porquanto esse responde diretamente por seus atos irregulares e/ou antieconômicos.

6.18. Os efeitos da pandemia não possuem o condão de atenuar a conduta de Roberto Ferreira Dias, porquanto essa resultou em irregularidade gravíssima com potencial de ocorrência de substancial dano ao erário (o que não ocorreu devido à atuação do TCU por meio de medida cautelar). Cabe ressaltar, nesse ponto, que, diferentemente do 2º Termo Aditivo, a celebração do 1º Termo Aditivo, que não foi ilegal, não se mostrou conduta reprovável suficiente para aplicação de sanção, não tendo o responsável ouvido em audiência sido apenado por diversos motivos, inclusive o cenário pandêmico.

6.19. Quanto à apenação da empresa contratada quanto à celebração do 2º Termo Aditivo, tem-se que essa não ocorreu, porquanto essa não se beneficiou da irregularidade (dano ao erário) graças à atuação do TCU de suspender cautelarmente os efeitos do aludido aditivo. De todo modo, tal argumentação não socorre a Roberto Ferreira Dias.

6.20. Por derradeiro, no exame da culpabilidade de Roberto Ferreira Dias, não há justificativa que ampare a presença de atenuantes, mas sim de agravantes como exposto no voto condutor do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário (peça 284). Nada, nem mesmo o período pandêmico, justifica a decisão pela celebração do 2º Termo Aditivo, quando esse foi realizado desprovido de estudos técnicos e de viabilidade jurídica, além de evidenciar a ocorrência de ato antieconômico para o contrato (aceitando proposta da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

empresa contratada por um 'meio termo', sem qualquer embasamento técnico por parte desta). Nesse ponto, ressalta-se que atos potenciais (abstratos) podem ser utilizados como agravantes de conduta de responsável, tais como dano ao erário potencial e intenção de conceder efeitos retroativos ao termo aditivo.

6.21. No que concerne à questão da responsabilidade subjetiva com base no Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), cabe assinalar que na aplicação de sanções, o TCU deve considerar a natureza e a gravidade da infração, os danos que delas provieram para a Administração Pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente, nos termos do art. 22, § 2º, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Acórdão 2463/2019-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro BRUNO DANTAS). Para fins de aplicação de sanções pelo TCU, deve-se verificar a ocorrência de culpa grave ou dolo do administrador público (Acórdão 11762/2018-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER).

6.22. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, erro grosseiro é o que decorreu de grave inobservância do dever de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave (Acórdãos 1689/2019-TCU-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES, 2924/2018-TCU-Plenário, rel. Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, e 2391/2018-TCU-Plenário, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER).

*6.23. **In casu**, conclui-se que a ilegalidade cometida (celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, cujos efeitos jurídicos foram suspensos cautelarmente por determinação do Tribunal de Contas da União e cuja nulidade veio a ser posteriormente declarada pelo Ministério da Saúde, instrumento que alterava substancialmente normas e condições originalmente estabelecidas na licitação, dando causa a modificação ou vantagem em favor da contratada Voetur/VTCLOG durante a execução contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual, ato que constitui indício do cometimento de fraude à licitação) foi praticada, no mínimo, com culpa grave (por imprudência e/ou negligência), tendo os responsáveis ora recorrentes assumido todos os riscos envolvidos na prática dos atos, pois era de se esperar deles a adoção de solução contratual embasada tecnicamente e juridicamente, adotando-se medidas que visassem a proteção e economicidade junto ao erário.*

6.24. Adotando-se o Acórdão 2599/2021-TCU-Plenário, rel. Ministro BRUNO DANTAS, tem-se que, para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) a decisão do gestor que desconsidera, sem a devida motivação, parecer da consultoria jurídica do órgão ou da entidade que dirige. Tal conduta revela desempenho aquém do esperado do administrador médio, o que configura culpa grave, passível de multa. Nesse sentido, tem-se o Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES.

6.25. Salienta-se, por oportuno, não haver nos presentes autos elementos hábeis a comprovar a ocorrência de circunstâncias práticas, ainda que de ordem estrutural, a limitar ou condicionar a ação dos responsáveis ora recorrentes na adoção de solução contratual embasada tecnicamente e juridicamente, adotando-se medidas que visassem a proteção e economicidade junto ao erário.

*6.26. De todo o exposto, propõe-se **rejeitar** a tese dos recorrentes.*

7. Desproporcionalidade e desarrazoabilidade das sanções

7.1. Os recorrentes apresentam a tese de que as sanções por eles sofridas seriam desproporcionais e desarrazoadas, tendo, para tanto, manifestado as seguintes situações (peças 310, p. 17-18; e 312, p. 25-28 e 30):

a) Roberto Ferreira Dias requer que sejam reduzidas as sanções a ele impostas, uma vez que essas foram desproporcionais e desarrazoadas, considerando a incompatibilidade do erro grosseiro ante a conduta realizada em cenário pandêmico, a impossibilidade de se considerar abstratamente condições agravantes, a ausência de dano ao erário e a ausência de dolo (peça 310, p. 17-18).

b) Alex Lial Marinho considera inadequada a pena de R$ 50.000,00 em razão de mera divergência de interpretação, tendo citado precedentes do TCU (Acórdãos 1882/2021-Plenário, rel. Ministro AROLDO CEDRAZ; 3573/2008-2ª Câmara, rel. Ministro UBIRATAN AGUIAR; 3340/2015-Plenário, rel. Ministro BRUNO DANTAS; 1624/2015-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN; 944/2016-TCU-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES; 976/2018-TCU-Plenário, rel. Ministro BRUNO DANTAS) - peça 312, p. 25-27 e 30; e

c) Alex Lial Marinho entende que não foram considerados os parâmetros da LINDB ao caso concreto (circunstâncias práticas a limitar ou condicionar a ação do agente público), uma vez que: (i) não teria sido considerado o ineditismo do contrato; (ii) o longo período em que se discutiu o termo 'item' (mais de dois anos); (iii) a omissão e incerteza da cláusula contratual; (iv) a falta de iniciativa e decisão dos gestores anteriores; (v) a pandemia; (vi) o número de pendências do Contrato 59/2018; (vii) as inúmeras atribuições

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

regimentais rotineiras; e (viii) os antecedentes do servidor (peça 312, p. 27-30). Citou precedentes do TCU (Acórdãos 60/2020-Plenário, rel. Ministra ANA ARRAES; 2463/2019-1ª Câmara, rel. Ministro BRUNO DANTAS; 4447/2020-Plenário, rel. Ministro AUGUSTO NARDES; 1628/2018-Plenário, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER) - peça 312, p. 28-29. Alex Lial Marinho menciona que não teria ocorrido dano ao erário (peça 312, p. 28).

Análise:

7.2. Quanto ao requerimento de Roberto Ferreira Dias para que sejam reduzidas as sanções a ele impostas, uma vez que teriam sido desproporcionais e desarrazoadas, considerando a incompatibilidade do erro grosseiro ante a conduta realizada em cenário pandêmico, a impossibilidade de se considerar abstratamente condições agravantes, a ausência de dano ao erário e a ausência de dolo; vê-se que esse não merece acolhimento.

7.3. Em que pese o cenário pandêmico, encontra-se plenamente justificada a gravidade da irregularidade na celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018, conforme se demonstra em excertos do voto condutor do acórdão condenatório (peça 284, p. 9-11):

> *65. O primeiro erro dos gestores foi assumir como verdadeira e sem maiores questionamentos essa premissa, baseada em uma simples interpretação literal do termo de referência. Ora, se a conclusão dessa interpretação levava a um resultado absurdo, deveriam ser buscados outros métodos interpretativos para a Administração balizar suas ações, o que não ocorreu (somente a nova gestão do Ministério elaborou uma análise sistemática do edital e concluiu pela validade da metodologia **SKU**).*
>
> *66. Sem convicção da tese, os gestores aventaram que a medição fosse por **SKU**, o que foi rechaçado pela contratada sem maiores contrapontos a respeito por parte da Administração, possivelmente porque acreditavam que a tese da 'unidade do produto' era a prevista no termo de referência.*
>
> *67. De forma a possivelmente buscar 'salvar' o contrato, os gestores aceitaram a proposta da contratada e aqui reside o segundo erro dos responsáveis. Isso porque não houve justificativas técnicas para o seu aceite. Há uma mera descrição do pleito da contratada e o singelo argumento de que sua proposta configura um 'meio termo'. Não foi feita uma análise se a métrica adotada para o serviço era a praticada no mercado e tampouco foi efetuada a razoabilidade do preço praticado.*
>
> *68. Esses dois erros dos responsáveis culminaram na celebração do 2º termo aditivo, representativo do terceiro erro dos responsáveis. Primeiro porque esse aditivo não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/1993, a qual não permite a alteração do contrato para sanar nulidade. Segundo porque o aditivo consistiu, em essência, na alteração de metodologia de medição, que na prática redundou no simples aumento do preço de determinado serviço licitado e contratado, consistindo em potencial burla ao regular certame licitatório e violação ao art. 41 da Lei 8.666/1993.*
>
> *69. Em outras palavras, em sendo constatada uma falha significativa no critério de medição, não cabe aos gestores negociar um 'meio termo' com a contratada, sob pena de violação do princípio da licitação prévia. O contrato está vinculado ao procedimento licitatório e às condições lá fixadas. Sendo estas impertinentes para a execução contratual, cabe anular o procedimento e não travar negociações ao arrepio da lei. (...)*
>
> *79. Entretanto, como visto, a ausência de pagamentos indevidos decorreu da pronta atuação do TCU e não de qualquer medida de precaução adotada pelos responsáveis. Assim, como o dano estaria configurado não fosse a ação dos órgãos de controle, considero configurada uma circunstância agravante da conduta dos gestores.*
>
> *80. Agrava a questão do dano potencial a intenção do sr. Roberto Ferreira Dias em atribuir efeitos retroativos ao aditivo, o que foi prontamente rechaçado pela Consultoria Jurídica (peça 67, p. 1).*
>
> *81. Outra circunstância agravante diz respeito à falta de justificativas técnicas para a celebração do segundo termo aditivo, caracterizando uma conduta desidiosa dos gestores. (...)*
>
> *84. Agrava, ainda, a conduta dos gestores a falta de adequado controle da execução do contrato em relação ao item objeto do segundo termo aditivo, pois, segundo a unidade técnica, 'o Ministério da Saúde não teria qualquer condição de examinar, verificar e atestar os quantitativos e valores declarados pela Voetur/VTCLOG, qualquer que fosse o 'método' adotado, uma vez que a empresa Voetur/VTCLOG, ao longo de todo o período de execução contratual, descumpriu as obrigações estabelecidas no item 7.5 do TR, negando ao Ministério da Saúde a permissão de acessar seu sistema de gerenciamento de armazéns (WMS – Warehouse Management System), com perfil que permitisse ao órgão contratante dispor de amplo acesso aos dados relacionados à prestação dos serviços contratados.' (Grifou-se).*

7.4. Como se depreende dos excertos transcritos no item precedente, as situações agravantes foram

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

três e bem caracterizadas e concretas. A ausência de dano ao erário não poderia ser um atenuante, uma vez que a ausência de pagamentos indevidos decorreu da pronta atuação do TCU e não de qualquer medida de precaução adotada pelos responsáveis. O dano potencial ao erário, ao contrário do que supõe Roberto Ferreira Dias, foi considerado circunstância agravante da conduta dos gestores. No que concerne à ausência de dolo, essa não foi considerada na dosimetria das penas aplicadas a Roberto Ferreira Dias, não podendo ser admitida como atenuante na seara administrativa e não penal ante a vastidão de situações agravantes listadas pelo Ministro-Relator ***a quo****.*

7.5. No que concerne à alegação de Alex Lial Marinho em que considera inadequada a pena de R$ 50.000,00 em razão de mera divergência de interpretação; tem-se que a irregularidade cometida é gravíssima e tinha o potencial de causar elevado dano ao erário. Não se trata de mera divergência de interpretação, mas de adoção de 'meio termo' proposto pela contratada, sem que houvesse quaisquer justificativas técnicas e amparo jurídico para tal, salientando-se que houve alertas da área técnica e da área jurídica do Ministério da Saúde quanto à possível antieconomicidade da celebração do 2º Termo Aditivo.

7.6. Em relação às alegações de Alex Lial Marinho de que não teriam sido considerados os parâmetros da LINDB ao caso concreto (circunstâncias práticas a limitar ou condicionar a ação do agente público), uma vez que: (i) não teria sido considerado o ineditismo do contrato; (ii) o longo período em que se discutiu o termo 'item' (mais de dois anos); (iii) a omissão e incerteza da cláusula contratual; (iv) a falta de iniciativa e decisão dos gestores anteriores; (v) a pandemia; (vi) o número de pendências do Contrato 59/2018; (vii) as inúmeras atribuições regimentais rotineiras; e (viii) os antecedentes do servidor - vê-se que essas não procedem. Com efeito, o cenário pandêmico não pode servir de anteparo para atenuar condutas eivadas de erros grosseiros de gestores públicos.

7.7. Quanto ao ineditismo do contrato, essa situação não tem o condão de atenuar os erros grosseiros dos gestores transcritos no item 7.5 supra. O fato de ser inédito não reduz a culpabilidade por aceitar 'meio termo' proposto pela contratada, sem que houvesse justificativas técnicas e amparo jurídico para tal.

7.8. No que tange ao longo período em que se discutiu o termo 'item' (mais de dois anos) e a omissão e incerteza da cláusula contratual, tem-se que tais circunstâncias não atenuam a conduta de Alex Lial Marinho, porquanto não refletiram em preocupação do ex-gestor na aceitação do 'meio termo' proposto pela contratada, sem que houvesse justificativas técnicas e amparo jurídico para tal.

7.9. A falta de iniciativa e decisão dos gestores anteriores não poderia ser considerada atenuante de conduta de Alex Lial Marinho, mas sim agravante da conduta dos gestores anteriores. Em relação ao número de pendências do Contrato 59/2018; às inúmeras atribuições regimentais rotineiras; tem-se que essas circunstâncias não atenuam a gravidade do erro grosseiro cometido, uma vez que o recorrente tinha consciência de tais pendências do Contrato 59/2018 (não foi elemento surpresa) e as inúmeras atribuições regimentais não foram provadas nestes autos.

7.10. Por fim, embora não expresso no voto do Ministro-Relator ***a quo****, entende-se que o atenuante de antecedentes do servidor deve ser sopesado em relação à evidente ausência de boa-fé do ex-gestor no cometimento da irregularidade tratada nestes autos. É importante ressaltar que a pena imposta a Alex Lial Marinho é significativamente inferior àquela aplicada a Roberto Ferreira Dias, além de ter sido considerado atenuante de grau hierárquico inferior em relação a Roberto Ferreira Dias e a não aplicação de todas as agravantes imputados a este. Obtemperando-se a multa já reduzida de R$ 50.000,00, ante a extrema gravidade da irregularidade cometida pelo ex-gestor, considera-se que essa foi adequada (razoável e proporcional) se considerados os antecedentes do recorrente, não merecendo reparos o juízo* ***a quo****.*

7.11. Quanto à ausência de dano ao erário levantada pelo recorrente Alex Lial Marinho, repisa-se que essa não poderia ser um atenuante, uma vez que a ausência de pagamentos indevidos decorreu da pronta atuação do TCU e não de qualquer medida de precaução adotada pelos responsáveis. O dano potencial ao erário, ao contrário do que supõe Alex Lial Marinho, foi considerado circunstância agravante da conduta dos gestores.

7.12. Em face do exposto, propõe-se ***refutar*** *a tese dos recorrentes.*

8. Ocorrência de boa-fé

8.1. Alex Lial Marinho teria agido de boa-fé (peça 312, p. 15).

Análise:

8.2. Quanto à questão da boa-fé de pessoa física, a jurisprudência deste Tribunal sedimentou entendimento de que quando se trata de processos atinentes ao exercício do controle financeiro da Administração Pública, tais como o que ora se examina, a boa-fé não pode ser presumida, devendo ser demonstrada e comprovada a partir dos elementos que integram os autos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

*8.3. Diante desse contexto, e após exame de toda a documentação carreada aos autos, não há como se vislumbrar a boa-fé na conduta de Alex Lial Marinho; já que não foram constatados atos ou fatos atenuantes os quais pudessem apontar à época da celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018 para atitude zelosa e diligente de Alex Lial Marinho na busca de justificativas técnicas e amparo jurídico para a celebração do 2º Termo Aditivo, considerando-se, ainda, a não busca pela economia ao erário em relação à forma de remuneração do item '**picking**'.*

8.4. No âmbito do TCU, é considerado de boa-fé o responsável que, embora tenha concorrido para o dano ao erário ou outra irregularidade, seguiu as normas pertinentes, os preceitos e os princípios do direito. A análise da conduta, portanto, é feita sob o ponto de vista objetivo, sem que seja necessária a comprovação de má-fé (dolo), mas apenas da ausência de boa-fé objetiva, para a responsabilização do agente (Acórdão 7936/2018-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN). Nesse sentido, tem-se os Acórdãos 13732/2019-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES; 8987/2018-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES; e 1921/2011-2ª Câmara, rel. Ministro RAIMUNDO CARREIRO.

*8.5. Assim sendo, propõe-se **não acolher** a tese de Alex Lial Marinho.*

9. Ausência de má-fé

9.1. Roberto Ferreira Dias não teria agido de má-fé (peça 310, p. 14 e 17).

Análise:

*9.2. De plano, **refuta-se** a tese do recorrente. Com efeito, não é necessário que haja má-fé ou ação dolosa do agente para fins de responsabilização perante o TCU (Acórdão 243/2010-TCU-Plenário, rel. Ministro AROLDO CEDRAZ). Nesse sentido, tem-se os Acórdãos 1358/2008-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN; 3441/2012-TCU-Plenário, rel. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES; 3694/2014-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro-Substituto ANDRÉ DE CARVALHO; 635/2017-TCU-Plenário, rel. Ministro AROLDO CEDRAZ; 827/2019-TCU-2ª Câmara, rel. Ministra ANA ARRAES; 4485/2020-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro BENJAMIN ZYMLER; e 2037/2022-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro VITAL DO RÊGO.*

9.3. Uma vez caracterizada a reprovabilidade da conduta, a avaliação de existência de má-fé não é requisito essencial à culpabilidade do recorrente. De outro modo, tal elemento anímico, subjetivo da conduta, deve ser considerado apenas como agravante, no sentido de majorar a dosimetria da pena.

9.4. Nesse sentido, considerando ainda que a má-fé não pode ser presumida, devendo, portanto, ser demonstrada, reforça-se que sua existência sequer foi cogitada nos presentes autos.

9.5. Assim, conclui-se que a alegação de ausência de má-fé do responsável não é capaz de afastar a cominação da multa, vez que não é pressuposto de sua aplicação. Ademais, tendo em vista que a manifestação de má-fé não foi expressamente considerada na dosimetria da pena, reputa-se irrelevante o argumento do recorrente.

CONCLUSÃO

*10. Das análises anteriores, conclui-se pela **negativa de provimento** dos recursos, considerando-se que:*

a) não ocorreu a prescrição para o exercício da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União à luz da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta no âmbito do TCU a Lei 9.873/1999;

b) culpabilidade grave dos gestores pela celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018, sem justificativas técnicas e amparo jurídico para tal, ensejando potencial elevado dano ao erário;

c) as penas impostas aos responsáveis ora recorrentes são razoáveis e proporcionais à gravidade da ilicitude de celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018, considerando-se a concretude de agravantes e atenuantes;

*d) a boa-fé não deve ser presumida mas sim demonstrada e comprovada, fato que não ocorreu nos presentes autos, já que não foram constatados atos ou fatos atenuantes os quais pudessem apontar à época da celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018 para atitude zelosa e diligente de Alex Lial Marinho na busca de justificativas técnicas e amparo jurídico para a celebração do 2º Termo Aditivo, considerando-se, ainda, a não busca pela economia ao erário em relação à forma de remuneração do item '**picking**'; e*

e) no âmbito do controle externo, a existência de má-fé não é requisito essencial à culpabilidade do responsável, bastando que tenha sido caracterizada a reprovabilidade da conduta.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior a presente análise dos pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho contra o Acórdão 651/2023-TCU-

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

Plenário, propondo-se, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer dos recursos e, no mérito, ***negar-lhes*** *provimento;*
b) dar ciência da deliberação que vier a ser adotada aos recorrentes, ao Ministério da Saúde, ao Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal, ao Departamento de Polícia Federal, à Controladoria-Geral da União, e aos demais interessados." (destaques no original)

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328323.

VOTO

Cuidam os autos, nesta etapa, de pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho contra o Acórdão 651/2023-TCU-Plenário (peça 283), da relatoria do Ministro Benjamin Zymler.

2. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ratifico o conhecimento dos recursos, proferido no despacho à peça 318.

3. A decisão recorrida foi prolatada no âmbito de representação de autoria dos senadores da República Eliziane Gama e Alessandro Vieira sobre possíveis irregularidades na formalização dos Termos Aditivos 1/2021 e 2/2021 ao Contrato 59/2018, firmado pelo Ministério da Saúde (MS) para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) do ministério, incluindo as atividades de Modernização Administrativa e Operação das Cadeias de Armazenamento e Distribuição desses insumos, sendo os serviços contratados sob demanda e sem disponibilização de mão de obra exclusiva.

4. No que interessa ao presente exame recursal, foram realizadas audiências e oitivas dos responsáveis em virtude da celebração do 2º termo aditivo ao contrato em análise, alterando substancialmente as normas e condições originalmente estabelecidas no edital da licitação e dando causa à modificação ou vantagem em favor da contratada durante a execução contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual. Tal irregularidade estava associada ao serviço "manipulação de item para atendimento (picking)".

5. Concluiu-se pela ocorrência de atos ilegais e antieconômicos e, por essa razão, no acórdão recorrido, o Tribunal aplicou aos responsáveis a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 (R$ 79.004,53 para Roberto Ferreira Dias e R$ 50.000,00 para Alex Lial Marinho) e inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da mesma lei.

6. Em apertada síntese, os recorrentes alegam que foram condenados pelo TCU apenas em virtude de divergência de interpretação sobre cláusula contratual. Assim, sustentam a ausência de culpabilidade na celebração do 2º Termo Aditivo do Contrato 59/2018, a desproporcionalidade das sanções e a ausência de má-fé (peças 310 e 312).

7. A Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) examinou os argumentos recursais, tendo concluído pela sua rejeição, com a consequente proposta de negar provimento ao pedido de reexame.

8. Acolho parcialmente os pareceres, adotando seus fundamentos como minhas razões de decidir naquilo que não contrariar o exposto neste voto.

9. Inicialmente, é preciso recordar os parâmetros estabelecidos pela Lei 13.655/2018, que alterou o Decreto-Lei 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), aplicáveis ao debate ora travado.

10. O art. 28 do aludido normativo dispõe que "o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro". No âmbito do TCU, a responsabilização de agentes públicos independe de dolo, bastando se caracterizar a culpabilidade do agente e, nos termos do art. 28 da LINDB, restar configurado o erro grosseiro em sua conduta.

11. Segundo a jurisprudência majoritária desta Corte, considera-se como erro grosseiro o que resulta de grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública (Acórdãos 2.391/2018-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler; 2.924/2018-Plenário, relator Ministro José Mucio

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328322.

Monteiro; 11.762/2018-Segunda Câmara relator Ministro Marcos Bemquerer; e 957/2019, 1.264/2019 e 1.689/2019, todos do Plenário, relator Ministro Augusto Nardes).

12. Noutro giro, sobre a aplicação de multa pelo TCU, é importante destacar que o art. 22, §2°, da LINDB (Decreto-lei 4.657/1942) preconiza que, "na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente".

13. A reanálise dos fatos tratados neste processo e dos argumentos trazidos pelos responsáveis em sede de recurso, a meu ver, confirmam a gravidade da irregularidade.

14. No entanto, entendo que cabe reparo na responsabilização, tendo em vista o grau distinto de atuação e culpabilidade dos responsáveis. Considero de maior gravidade a conduta do sr. Roberto Ferreira Dias, na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (DLOG/MS), por, em essência, ignorar o parecer da consultoria jurídica que especificava uma série de fragilidades na proposta de alteração do contrato e alertava para a necessidade de demonstração de que a alteração traria benefícios técnicos e econômicos para a Administração, fundamentados em regras claras e tecnicamente comprováveis.

15. Essa conduta se materializou na confecção da Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS (peça 152, p.36-38), assinada exclusivamente por esse responsável, na qual refuta, de forma superficial, os riscos apontados pela Conjur/MS e se manifesta favorável à realização do aditivo contratual para o item do contrato relativo ao *picking*. Foi com base nesse parecer que o termo aditivo foi posteriormente firmado entre o DLOG/MS e a empresa VTCLog (peça 152, p. 59).

16. Conforme enunciado da jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.264/2019-Plenário, relator: Ministro Augusto Nardes; e Acórdão 2.599/2021-Plenário, relator: Ministro Bruno Dantas):

> "*Para fins de responsabilização perante o TCU,* ***pode ser tipificada como erro grosseiro*** *(art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)* ***a decisão do gestor que desconsidera, sem a devida motivação, parecer da consultoria jurídica*** *do órgão ou da entidade que dirige. Tal conduta revela desempenho aquém do esperado do administrador médio,* ***o que configura culpa grave, passível de multa***." (destaques acrescidos)

17. No mesmo sentido, tem-se o enunciado resultante do Acórdão 2.503/2024-2ª Câmara, (relator: Ministro Aroldo Cedraz):

> *"Para fins de responsabilização perante o TCU, a decisão do gestor que desconsidera, sem a devida motivação, as recomendações constantes do parecer da consultoria jurídica acerca do processo licitatório configura erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb)."*

18. Desse modo, em concordância com o parecer da AudRecursos, entendo que os atos do sr. Roberto Ferreira Dias configuraram erro grosseiro, em contrato de alta materialidade e relevância social. Assim, as sanções aplicadas pelo Tribunal não merecem reparos quanto ao referido responsável.

19. Embora seja procedente o argumento de que o contrato possuía fragilidades desde sua origem, o que impactou a sua execução, gerando interrupção de pagamentos à contratada, não há qualquer justificativa plausível para a efetivação de uma alteração contratual sem embasamento técnico que justificasse adequadamente os impactos financeiros previstos para o Ministério da Saúde. Sem dúvida, o gestor deveria ter embasado essa decisão de forma robusta, o que não foi feito.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328322.

20. Mesmo em contexto extraordinário, como foi o caso, os princípios basilares da Administração Pública não podem ser ignorados pelo gestor público, com destaque para os princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e eficiência, com fulcro no art. 2º da Lei 9.784/1999. A propósito, cabe lembrar que esse dispositivo exige que os processos administrativos indiquem os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão.

21. Ademais, este Tribunal não ignorou o contexto de enfrentamento da pandemia de covid-19, como alegam os recorrentes. Certamente, a conduta do responsável deveria se pautar por cautela para evitar uma eventual rescisão de contrato, que era imprescindível para a logística de distribuição de vacinas e outros insumos necessários ao combate da grave crise de saúde pública ocasionada pela covid-19. No entanto, essa circunstância, de forma alguma, pode ser entendida como salvo-conduto para a prática de atos ilegais, imotivados e antieconômicos.

22. Com relação ao sr. Alex Lial Marinho, no entanto, entendo que a aplicação da sanção se mostra desproporcional à sua atuação nos procedimentos atinentes à alteração contratual em exame, considerando a documentação constante dos autos. Isso porque a sua manifestação, por meio da Nota Informativa 14/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, visou apresentar esclarecimentos à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, que, por meio de despacho, informou sobre a necessidade de complementação das justificativas apresentadas aos questionamentos da Conjur (peça 152, p. 45-46).

23. Assim, a meu ver, tal manifestação de autoria desse responsável não possuía efeito decisório, já que a demanda, com o respectivo embasamento, já havia sido formalizada pelo DLOG por intermédio da Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS.

24. Desse modo, assiste razão ao recorrente quando afirma que (peça 312, p. 22):

> *"tenta-se imputar uma 'plena concordância' do Recorrente, com o teor da Nota Técnica 4/2021, elaborada isoladamente pelo Diretor do Departamento Logístico, afirmação realizada pela Unidade Técnica em desconformidade com o poder hierárquico da Administração Pública, que pode, de forma legítima, avocar competências dos seus subordinados.*
>
> ***Não cabe anuir, fiscalizar ou manifestar concordância com ato de superior, em razão do poder hierárquico. O Despacho elaborado pelo Recorrente, repisa-se, foi de natureza de impulsão do processo**, sem constar qualquer juízo de valor sobre as considerações elaboradas pelo superior, pois não lhe era cabido tal ato de censura."* (destaques acrescidos)

25. Importa destacar que, como bem pontuado no voto condutor do acórdão recorrido, o sr. Alex Lial Marinho participou do processo decisório ao se manifestar de acordo com o teor da Nota Técnica 2/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS, elaborada pelos fiscais do contrato e emitida em 4/3/2021. Tal nota deu origem a todo o processo administrativo para a alteração do contrato em questão (peça 152, p. 7).

26. Nada obstante, observo que, considerando o trâmite desse processo nas áreas competentes do Ministério, as graves deficiências de fundamentação verificadas na proposta de termo aditivo foram objeto de manifestação pela Conjur em etapa posterior à emissão da supramencionada nota técnica da CGLOG.

27. No retorno dos autos ao Departamento de Logística em Saúde para a devida complementação dos fundamentos para a alteração contratual, o Sr. Alex Lial Marinho já não atuou com capacidade decisória. Isso porque, como acima ressaltado, o seu superior hierárquico foi responsável pela elaboração da Nota Técnica 4/2021-CGLOG/DLOG/SE/MS e pela decisão de assinatura do termo aditivo, contrariando de forma injustificada as recomendações da Conjur (peça 152, p. 38).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328322.

28. Considerando esses fatores, entendo que a conduta desse responsável não configurou erro grosseiro, cabendo dar provimento ao pedido de reexame para afastar a aplicação de multa efetuada pelo acórdão recorrido.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a minuta de acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2024.

JORGE OLIVEIRA

Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328322.

ACÓRDÃO Nº 1861/2024 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 025.828/2021-5
1.1. Apensos: 028.099/2020-6; 034.053/2023-9
2. Grupo I – Classe de Assunto: I – Pedido de Reexame (em Representação)
3. Recorrentes: Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98); Alex Lial Marinho (051.576.527-98)
4. Unidade: Ministério da Saúde
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler
5.2. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos)
8. Representação legal: Caio Chaves Morau (357.111/OAB-SP), representando Alessandro Vieira; André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando Alex Lial Marinho; Teresa Raquel Figueredo da Silva (67640/OAB-DF), representando Roberto Ferreira Dias; Paula Echamende Lindoso Baumann (24172/OAB-DF), Andreia da Silva Lima (25408/OAB-DF) e outros, representando VTC Operadora Logística Ltda.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho contra o Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal de Contas da União aplicou multa a ambos e a pena de inabilitação ao primeiro, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública.

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 32, inciso III, da Lei 8.443/1992, em:

9.1. conhecer do recurso interposto por Roberto Ferreira Dias, para, no mérito, negar-lhe provimento;

9.2. conhecer do recurso interposto por Alex Lial Marinho, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário quanto a este responsável;

9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao Ministério da Saúde.

10. Ata n° 37/2024 – Plenário.
11. Data da Sessão: 11/9/2024 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1861-37/24-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Benjamin Zymler (Revisor), Augusto Nardes, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira (Relator), Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76328321.